

刑法
No181

共通問題 R2-5

(配点: 2)

月	日
月	日

共犯と錯誤に関する次のアからオまでの各記述を判例の立場に従って検討した場合、正しいものの個数を後記1から5までの中から選びなさい。

- ア. 甲及び乙がAに対する暴行を共謀したが、Aの態度に激高した甲が殺意をもってAを殺害した場合、甲及び乙に殺人罪の共同正犯が成立するが、乙は傷害致死罪の刑で処断される。
- イ. 甲及び乙がAに対する強盗を共謀したが、その強盗の機会に、甲が過失によってAに傷害を負わせた場合、甲及び乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立する。
- ウ. 甲及び乙が共謀して、公務員Aに虚偽の内容の公文書の作成を教唆することにしたが、乙はAを買収することに失敗したため、甲に無断で、Bに公文書を偽造することを教唆し、Bが公文書を偽造した場合、甲に虚偽公文書作成罪の教唆犯が成立する。
- エ. 甲が乙にA方に侵入して金品を窃取するように教唆して、その犯行を決意させたが、乙はA方と誤認して隣のB方に侵入してしまい、B方から金品を窃取した場合、甲にB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯は成立しない。
- オ. 甲が乙の傷害行為を幫助する意思で、乙に包丁を貸与したところ、乙が殺意をもってその包丁でAを刺殺した場合、甲に殺人罪の幫助犯が成立し、傷害致死罪の幫助犯は成立しない。
1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個

No181	共犯と錯誤	正答率
共通R2-5	正 解	43%

ア 誤っている

最決昭 54.4.13 (百選 I 92 事件) は、「殺人罪と傷害致死罪とは、殺意の有無という主観的な面に差異があるだけで、その余の犯罪構成要件要素はいずれも同一であるから……殺意のなかつた被告人……については、殺人罪の共同正犯と傷害致死罪の共同正犯の構成要件が重なり合う限度で軽い傷害致死罪の共同正犯が成立するものと解すべきである」としている。したがって、暴行の故意しか有していなかった乙には、傷害致死罪の共同正犯が成立する。

イ 正しい

結果的加重犯の共同正犯の成否が問題となる。強盗を共謀し、実行した者のうち1人が、逃走するため警察官を死亡させた事案で、最判昭 26.3.27 (百選 I [第7版] 79 事件) は、「右Aの傷害致死行為は強盗の機会において為されたものといわなければならないのであって、強盗について共謀した共犯者等はその一人が強盗の機会において為した行為については他の共犯者も責任を負う」として、強盗致死罪の成立を認めている。したがって、甲及び乙がAに対する強盗を共謀したが、その強盗の機会に、甲が過失によってAに傷害を負わせた場合、甲及び乙に強盗致傷罪の共同正犯が成立する。

ウ 誤っている

最判昭 23.10.23 は、公文書偽造罪の教唆犯が成立するとしている。その理由として、判例は、「本件故意の内容は刑法第 156 条の罪の教唆であり結果は同法第 155 条の罪の教唆であ」り、「両者は犯罪の構成要件を異にするもその罪質を同じくするものであり且法定刑も同じである、而して右両者の動機目的は全く同一である……共謀者の一人たる A が……共謀に基づいてたまたまその具体的手段を変更したに過ぎないから両者の間には相当因果関係があるものと認められる……即ち被告人は法律上本件公文書偽造教唆につき故意を阻却しない」としている。したがって、甲には公文書偽造罪の教唆犯が成立する。

エ 誤っている

大判大 9.3.16 は、教唆犯内の錯誤が同一構成要件の範囲内に属する限り、故意は阻却されず教唆犯が成立するとしている。本記述では、甲は乙に対してA方への住居侵入及び窃盗を教唆したところ、乙はB方へ侵入し窃盗を実行している。すなわち、甲の錯誤は同一構成要件の範囲内に属する。したがって、甲にはB方への住居侵入罪及びBに対する窃盗罪の教唆犯が成立する。

オ 誤っている

結果的加重犯と共犯の成否について、暴行を教唆したところ、被教唆者が被害者を傷害した結果死亡させた事案において、判例 (大判大 13.4.29) は、教唆者も傷害致死の罪責に任すべきものとしている。また、共犯と錯誤について、住居侵入窃盗を教唆したところ、正犯が住居侵入強盗を実行した事案において、判例 (最判昭 25.7.11) は、住居侵入窃盗罪の教唆犯が成立するとしている。本記述は幫助の事案であるが、上記各判例の立場に従えば、甲に傷害致死罪の幫助犯が成立する。

以上により、正しい記述はイの1個であり、したがって、正解は肢2となる。